

1501052-35.2021.8.26.0126

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: JULIO DA SILVA BRANCHINI

Comarca: Caraguatatuba

Foro: Foro de Caraguatatuba

Vara: Vara Criminal

Data de Disponibilização: 23/02/2022

... do crime de associação ao tráfico, a seguir: "HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM DE QUE TERIA HAVIDO ASSOCIAÇÃO EVENTUAL. NECESSIDADE DE ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Caraguatatuba

Foro de Caraguatatuba

Vara Criminal

Praça Doutor José Rebello da Cunha, 73, ., Sumaré - CEP 11660-050, Fone: (12) 3882-3099, Caraguatatuba-SP - E-mail: caragua1cr@tjsp.jus.br

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo Digital nº:

1501052-35.2021.8.26.0126

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência - 18763837 -

DEL.POL.CARAGUATATUBA, 2005/21/301 - DEL.POL.CARAGUATATUBA

Réu:

CLEBER AUGUSTO GIMENES DE FARIAS

Data da Audiência:

22/02/2022

Réu Preso

A S S E N T A D A

Aos 22 de fevereiro de 2022, às 15 horas e 40 minutos, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, excepcionalmente por meio virtual utilizando-se a ferramenta Microsoft Teams, diante da Pandemia do COVID-19 e da restrição de acesso das pessoas ao prédio do Fórum, sob a presidência do(a) Meritíssimo(a) Juiz(íza) da Vara Criminal da Comarca de Caraguatatuba, Dr. Júlio da Silva Branchini - Juiz de Direito, onde o mesmo se encontrava, comigo, escrevente a seu cargo, no final nomeado e assinado, sendo representante do Ministério Público o(a) Dr.(a) Alexandre Petry Henlana - Promotor(a) de Justiça. Apregoadas as partes, presente o réu, Cleber Augusto Gimenes de Farias (videoconferência), acompanhado por seu defensor Dr.(a) Luan Campos Boldrini. Presentes as testemunhas da acusação, a saber: Henrique Zamoneiro Silis e Gustavo André Ribeiro.

INICIADOS OS TRABALHOS: com a concordância das partes, por meio virtual foram colhidos os depoimentos das testemunhas arroladas pela acusação, Henrique Zamoneiro Silis e Gustavo André Ribeiro, finalmente foi realizado o interrogatório do acusado. Todos os depoimentos e o interrogatório foram colhidos por meio do sistema de gravação da ferramenta Microsoft Teams, nos termos do artigo 405, § 2º, do CPP

(redação da Lei nº 11.719/08). Tanto pelo Promotor de Justiça quanto pelo defensor do réu, foi dito que não haviam requerimentos a serem feitos na fase do artigo 402 do CPP.

Pelo MM. Juiz foi dito: “Declaro encerrada a instrução. Em sede de debates orais o Ministério Público pugnou pela procedência da ação nos exatos termos da denúncia. A defesa, a seu turno, requereu a absolvição do réu. Vistos. CLEBER AUGUSTO GIMENES DE FARIAS, qualificado nos autos, foi denunciado como incurso no artigo 33, caput, e artigo 35, ambos com a causa de aumento do artigo 40, inciso VI, todos da Lei nº 11.343/06. Segundo narra a denúncia e o que consta dos inclusos autos de inquérito policial, que em data incerta, porém, anteriormente ao dia 28 de junho de 2021 e pelo menos até a referida data, CLEBER AUGUSTO GIMENES DE FARIAS associou-se com o adolescente K. A. R. e outras pessoas desconhecidas para o fim de praticarem, reiteradamente ou não, o crime de tráfico de drogas. Consta ainda que no dia 28 de junho de 2021, às 19:00 horas, na Rua Benedito Mariano Nepomuceno, nº 1.049 – Benfica, Centro, nesta cidade e Comarca de Caraguatatuba/SP, o acusado, com o envolvimento do adolescente K. A. R., trazia consigo, guardava e tinha em depósito 20 (vinte) porções de Crack, com peso de 16,29g; 10 (dez) porções de Cocaína, com peso de 10,49g; 60 (sessenta) porções de Crack, com peso de 47,41g e 45 (quarenta e cinco) porções de Cocaína, com peso de 45,33g, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar. A denúncia foi recebida em 01 de julho de 2021 (fls. 92/93). O réu foi citado (fls. 115) e apresentou resposta à acusação (fls. 133/134). Durante a instrução, foram ouvidas as testemunhas arroladas em comum, bem como foi realizado o interrogatório do réu, tudo por intermédio de sistema audiovisual, constando as respectivas gravações armazenadas na mídia. Encerrada a instrução criminal, na fase do artigo 402 do CPP, as partes nada requereram. O Ministério Público apresentou alegações finais orais, pugnando pela procedência da ação, nos exatos termos da denúncia. A Defesa, por seu turno, requereu a absolvição do réu. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. A ação é PARCIALMENTE PROCEDENTE. A ação é PROCEDENTE em relação ao delito de tráfico e IMPROCEDENTE no que toca ao delito de associação ao tráfico. Senão vejamos. Em relação ao delito previsto no artigo 33 da Lei de Drogas, a materialidade delitiva é comprovada por meio do auto de prisão em flagrante e demais peças que o acompanham, boletim de ocorrência (fls. 11/15), auto de prisão em flagrante (fls. 10), auto de exibição e apreensão (fls. 25), auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 26), laudo pericial (fls. 121/124 e 142/144), que confirmam a natureza das substâncias apreendidas e demais provas produzidas nos autos. A autoria delitiva, também, restou demonstrada e caracterizada nos autos. A testemunha e policial militar HENRIQUE ZOMONELO SILIS informou, na delegacia, que juntamente com seu colega de farda, são integrantes embarcados na VTR I20 239. Informa que em patrulhamento pelo centro desta urbe, enquanto passavam em frente ao “escadão do Benfica”, local já conhecido em decorrência de diversas ocorrências policiais vinculadas ao tráfico, como sendo ponto conhecido pela mercancia de entorpecentes, realizaram observar dois indivíduos, sendo que estes ao verificarem se tratar de viatura policial, empreenderam fuga, sendo que o indivíduo, identificado como sendo o menor de idade Kaique Augusto Ribeiro pulou para dentro de uma residência tentando fugir, contudo acabou sendo contido, nos fundos da residência, posto que ocorreu o encalço deste. Informa o depoente que o outro rapaz, já identificado como Cleber Augusto Gimenes de Farias, maior correu pela rua lateral e foi contido ali mesmo pela equipe. No momento da abordagem, junto ao adolescente Kaique foi encontrado uma sacola verde contendo (60 pedras de crack e 45 porções de cocaína vácuo) e junto ao senhor Cleber foi encontrado em seus bolsos da jaqueta a quantia de 20 pedras de crack e 10 embalagens de cocaína a vácuo e, a quantia de R\$ 80 reais. Diante dos fatos aqui narrados, comparece para registro e para que seja tomada as providências de Polícia Judiciária, informando que ambos assumiram que ali se encontravam realizando a venda de drogas pelo local. Em Juízo, manteve a versão da fase policial. A testemunha e policial militar GUSTAVO ANDRE RIBEIRO que também

participou dos fatos narrados da denúncia, na delegacia e em Juízo, prestou depoimento corroborando a versão narrada por seu colega. Em seu interrogatório policial o réu CLEBER AUGUSTO GIMENES DE FARIAS disse que realmente foi surpreendido pelos policiais quando estava no local o qual é "biqueira". Alega que é seu segundo dia vendendo drogas ali. Alega que ganha cerca de trinta reais por cada venda de "kit", "isso dá em média trezentos reais por dia". Afirma que estava na posse de crack quando de sua abordagem e que indicou onde estava o restante do entorpecente. No local estava na companhia de Kaique o qual o conheceu a uma semana e que o mesmo também realiza a venda ali, e que no momento da abordagem ele saiu correndo para fugir e se esconder. Em Juízo, negou a prática do crime. Como se vê, o conjunto probatório é suficiente para condenar o réu pelo crime de tráfico. Isto porque, as declarações dos policiais militares foram coesas desde a fase inquisitiva. Além disso, a forma de acondicionamento dos entorpecentes, a dinâmica da abordagem, o comportamento do acusado logo antes da apreensão, bem como o local, conhecido como ponto de tráfico, demonstram a autoria delitiva. Ademais, o próprio acusado confessou, na fase policial, que estava no local realizando o comércio de drogas, juntamente com o adolescente K. A. R. Consigne-se que a impugnação à valoração do depoimento dos policiais deve ser afastada, vez que inexistente qualquer elemento apto a sustentar a alegação de suspeição. Está pacificado na jurisprudência que a condição de policial seja militar ou civil, estadual, federal ou municipal, por si só, não invalida o seu testemunho, porquanto ele não está impedido de depor e se sujeita a compromisso como outra testemunha qualquer, *litteris*: Conforme entendimento desta Corte, o depoimento de policiais responsáveis pela prisão em flagrante do acusado constitui meio de prova idôneo a embasar o édito condenatório, mormente quando corroborado em Juízo, no âmbito do devido processo legal. (HC 146.381/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 17.06.10, DJe 09.08.10). Registre-se que, além de não demonstrado o interesse dos policiais em prejudica-lo, o depoimento deles "podem ser meio de prova idôneo para embasar a condenação, principalmente quando tomados em juízo, sob o crivo do contraditório. Precedentes do STF e desta Corte". (STJ - HC 40162/MS, Min. Gilson Dipp, DJ 28.03.2005). No mesmo sentido: "Os policiais não se encontram legalmente impedidos de depor sobre atos de ofício nos processos de cuja fase investigatória tenham participado, no exercício de suas funções, revestindo-se tais depoimentos de inquestionável eficácia probatória, sobretudo quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório. Precedentes desta Corte e do Supremo Tribunal Federal" (Superior Laurita Vaz DJ 04.05.2011). Nota-se, portanto, que a traficância restou devidamente caracterizada, já que, conforme lição de Luiz Flávio Gomes, "Para se concluir pela prática do crime de tráfico, não basta, em princípio, a quantidade (ou qualidade) da droga apreendida. Deve-se atentar, ainda, para outros fatores, tais como o local e as condições em que se desenvolveu a ação criminosa, as circunstâncias da prisão, a conduta, a qualificação e os antecedentes do agente (art. 52, I)" (In EL TASSE, Adel et. al. Legislação Criminal Especial. Vl. 6. São Paulo: Editora RT, 2009, p. 197). O conjunto probatório produzido sob a garantia do contraditório judicial é harmônico com os elementos informativos colhidos na fase inquisitória, ambos indicando que os réus traziam consigo os entorpecentes descritos na denúncia, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar, sabendo da sua destinação ao tráfico de entorpecentes. Ainda, viável a incidência da causa de aumento disposta no artigo 40, inciso VI, da lei de drogas, uma vez que o réu praticou a infração junto com o adolescente K. A. R, conforme noticiado nos depoimentos das testemunhas policiais. Destarte, afastando as teses apresentadas pela defesa, é de rigor a procedência do pedido previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI da Lei n.º 11.343/06. De outro lado, quanto o delito previsto no artigo 35 da Lei 11.343/06, é de rigor a absolvição. Sobre o referido delito, é importante destacar posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, que ressalta a necessidade de demonstração do vínculo de estabilidade para a caracterização do crime de associação ao tráfico, a seguir: "HABEAS CORPUS. PACIENTES CONDENADOS POR TRÁFICO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME PREVISTO NO ARTIGO 35 DA LEI 11.343/2006. RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS DE ORIGEM DE QUE TERIA HAVIDO ASSOCIAÇÃO

EVENTUAL.NECESSIDADE DE ESTABILIDADE OU PERMANÊNCIA PARA A CARACTERIZAÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EXISTENTE. ABSOLVIÇÃO QUANTO À ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. CONCESSÃO DA ORDEM. 1. Diante da expressão "reiteradamente ou não", contida no caput do artigo 35 da Lei 11.343/2006, há que se perquirir se para a configuração do delito de associação para o tráfico basta a convergência ocasional de vontades ou a eventual colaboração entre pessoas para a prática delituosa, ou se é necessário, tal como no crime de quadrilha ou bando previsto no Código Penal, que a reunião se dê de forma estável. 2. Para a caracterização do crime de associação para o tráfico, é imprescindível o dolo de se associar com estabilidade e permanência, sendo que a reunião ocasional de duas ou mais pessoas não se subsume ao tipo do artigo 35 da Lei 11.343/2006. Doutrina.Precedentes. 3. As instâncias de origem, tendo reconhecido que a reunião dos pacientes teria sido eventual, a admitiram como apta a configurar o delito de associação para o tráfico, o que contraria a interpretação majoritária que tem sido conferida ao tipo do artigo 35 da Lei de Drogas. 4. Não havendo qualquer registro, quer na denúncia, na sentença condenatória, ou no aresto que a confirmou, de que a associação dos pacientes teria alguma estabilidade ou caráter permanente, não há que se falar no delito de associação para o tráfico, estando-se diante de mero concurso de pessoas. 5. Ordem concedida apenas para absolver os pacientes do delito de associação para o tráfico, mantendo-se, quanto ao mais, a sentença condenatória prolatada na origem." (STJ - HC: 137471 MS 2009/0101923-9, Relator: Ministro JORGE MUSSI, Data de Julgamento: 02/09/2010, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/11/2010). Assim também se posiciona o Supremo Tribunal Federal: Ementa: "HABEAS CORPUS. PENAL. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. ART. 35 DA LEI 11.343/2006. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO VÍNCULO ASSOCIATIVO. ORDEM CONCEDIDA. 1. O verbo núcleo do tipo previsto no art. 35 da Lei 11.343/2006 é associar-se. Portanto, a caracterização da associação para o tráfico de drogas depende da demonstração do vínculo de estabilidade entre duas ou mais pessoas, não sendo suficiente a união ocasional e episódica. Não se pode transformar o crime de associação, que é um delito contra a paz pública – capaz de expor a risco o bem jurídico tutelado –, em um concurso de agentes. Doutrina e jurisprudência. 2. No particular, concluiu-se pela condenação tão somente em razão da convergência ocasional de vontades para a prática do crime de tráfico. Noutras palavras, não se separou a vontade de se associar da vontade necessária para a prática do crime pretendido. 3. "Não é questão de prova saber-se da tipicidade de determinado fato, cuja veracidade não se discute, mas se admite como afirmado na sentença: cuida-se de simples qualificação jurídica de fato, operação à qual sempre se prestou o habeas corpus" (RHC 75236; Relator (a): Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Segunda Turma, DJ 1º/8/1997). 4. Habeas corpus concedido para absolver a paciente do crime de associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei 11.343/2006), com extensão da ordem à corré." (STF - HC: 124164 AC, Relator: Min. TEORI ZAVASCKI, Data de Julgamento: 11/11/2014, Segunda Turma, Data de Publicação: DJe-230 DIVULG 21-11-2014 PUBLIC 24-11-2014). Destarte, seguindo esta orientação jurisprudencial, compreendo que as provas coligidas não se mostraram capazes de demonstrar elo estável e permanente entre o réu e o adolescente. Ressalto que o breve acompanhamento descrito pelos policiais não pode ser considerado meio hábil a comprovar a permanência e estabilidade que o tipo penal em comento demanda. Assim, apesar da existência de indícios, tais indícios não se tornaram em provas suficientes para sustentar uma condenação, sendo, portanto, a absolvição medida que se impõe. Apurada a responsabilidade, passo a fixar a pena atendendo ao método trifásico da dosimetria. Na primeira fase, nos termos do artigo 59 do Código Penal c.c. artigo 42 da Lei 11.343/06, não há circunstâncias que ensejem elevação da pena-base, razão pela qual fixo a mesma no mínimo legal, ou seja, 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa. Na segunda fase inexistem circunstâncias agravantes. Presentes as atenuantes da menoridade relativa, contudo, considerando que a pena já se encontra no mínimo, inviável reduzi-la nesta etapa da dosimetria, em observância ao disposto na súmula 231 do C. Superior Tribunal de Justiça. Na terceira fase, presente a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso, VI da Lei nº 11.343/06, logo, aumento a pena em 1/6, resultando em 05 (cinco) anos e 10 (dez)

meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Tendo em vista que o réu trazia consigo vultosa quantidade de entorpecentes, compreendo que não estão preenchidos os requisitos do § 4.º do artigo 33 da Lei nº 11.343/06. Por isso, fixo a pena para o delito previsto no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06 em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa. Ante a ausência de informações da capacidade econômica do acusado, fixo a valor de cada dia multa no mínimo legal. Observando-se o disposto na súmula 719 do STF, para fins de estabelecimento do regime inicial de cumprimento de pena, anoto que, inobstante a primariedade do acusado, conheço que o regime prisional adequado para início de cumprimento da censura penal deva ser o regime mais severo - fechado. Isto porque, o acusado recrutou um adolescente para participar da conduta criminosa. Assim, vislumbra-se que a culpabilidade extrapola aquela elementar à espécie, ressaíndo do ordinário. Para a aplicação da detração penal do art. 387, §2º, CPP, necessário o preenchimento de requisitos objetivos e subjetivos. No presente caso, inexistente prova do requisito subjetivo. Ausentes os requisitos legais do art. 44 do Código Penal, incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos para o réu. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação para CONDENAR o réu CLEBER AUGUSTO GIMENES DE FARIAS, à pena de 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão em regime inicial FECHADO, além de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, no mínimo legal, pela prática do crime previsto no artigo 33, caput, c/c artigo 40, inciso VI da Lei nº 11.343/06. Ainda, ABSOLVO o réu da prática do delito previsto no artigo 35, caput, da Lei 11.343/06, nos termos do art. 386, VII do CPP. Presentes os pressupostos de manutenção da prisão cautelar, deve ser afastada a possibilidade de recurso em liberdade. Ademais, fixado o regime fechado para o início de cumprimento da pena privativa de liberdade, inexistente desproporcionalidade na permanência da prisão provisória. Destarte, nego o direito de o réu recorrer em liberdade. Recomende-se ao local em que se encontra recolhido. Expeça-se guia de recolhimento provisória. DECRETO O PERDIMENTO do valor e dos objetos apreendidos em favor da União. Custas ex lege. Após o trânsito em julgado: Após o trânsito em julgado: I) Comunique-se à Justiça Eleitoral, para os fins do artigo 15, inciso III, da CRFB/88, bem como IIRGD. II) Comunique-se o Juízo da Execução, para aditamento da Guia de Recolhimento, encaminhando-se as peças necessárias. III) Tendo em vista a aplicação de pena de multa, feito eventual abatimento em caso de fiança recolhida (art. 479 das NSCGJ), intime-se o réu para pagamento do valor, em 10 (dez) dias, sob pena de execução forçada. - Caso o réu recolha o valor, comunique-se o Juízo da Execução Criminal. - Decorrido o prazo sem manifestação ou não localizado o réu, expeça-se certidão de sentença, de acordo com o modelo próprio do Sistema SAJ - Categoria 2 (Certidões), Modelo 505791, e abra-se vista ao Ministério Público, após o que deverá ser lançada a movimentação "Cód. 62050 - Autos no Prazo - Execução da Multa Penal". - Comunicada a distribuição da Execução da multa na Vara de Execução competente, proceda-se à anotação no Histórico de Partes, inserindo o evento "Cód. 17 - Início da Execução da Pena de Multa", indicando no complemento o número do processo de execução, arquivando-se os autos, após, com as anotações de praxe. IV) Oficie-se à autoridade policial para incineração da contraprova. V) Oficie-se para que o banco depositário providencie a transferência do valor apreendido ao Fundo Nacional Antidrogas - Funad. VI) Comunique-se o Sr. Escrivão Judicial, responsável pela Seção de Depósito e Guarda de Objetos, acerca do perdimento dos objetos apreendidos. Oportunamente, arquivem-se os autos, com as cautelas e anotações de praxe. P.I.C. Pelo Ministério Público foi dito que NÃO DESEJA RECORRER da decisão, ficando, nesta data, transitada em julgado a r. sentença para acusação. Pela defesa foi dito que DESEJA RECORRER da decisão. Recebo o recurso para que surta seus efeitos jurídicos e legais. Expeça-se Guia de Recolhimento Provisória imediatamente. Abra-se vista a defesa para apresentação das razões de apelação. Após, vista ao Ministério Público para contrarrazões. Regularizados os autos, remetam-se ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as cautelas de praxe. Publicada esta em audiência, saem os presentes intimados". NADA MAIS. Eu, _____, (Bruno Bianchini), Escrevente, digitei e providenciei a impressão.

Júlio da Silva Branchini
Juiz de Direito

As gravações referentes às oitivas realizadas nos autos podem ser acessadas através do seguinte endereço eletrônico:

https://tjsp-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/bbianchini_tjsp_jus_br/EpSXP92eUpDsoD_dpqHin4BNyNm183gcS2YfJlxRsI6hw?e=gjbo6C